

CONTRATOS EN GENERAL

CAPÍTULO I - NOCIONES GENERALES

§ 1.— Concepto

1. Definición; contrato, convención y convención jurídica

Según el artículo 957, "el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales".

La definición dada por el Código Civil y Comercial hace hincapié en dos aspectos importantes. Por un lado, **el acuerdo de voluntades manifestado en el consentimiento tiende a reglar relaciones jurídicas con contenido patrimonial**. Por el otro, recepta un contenido amplio del contrato, desde que abarca no solo la creación de tal relación jurídica, sino también las diferentes vicisitudes que ella puede tener, tales como las modificaciones que las partes puedan introducir con posterioridad a la celebración del contrato, la transferencia a terceros de las obligaciones y derechos que nacen del contrato y hasta la extinción misma del contrato por acuerdo de voluntades.

Nuestro Código se inclina por formular la distinción antes señalada, pues el artículo 957 —como se ha visto— se refiere a las relaciones jurídicas patrimoniales, en tanto que **el artículo 1003 establece que el objeto del contrato debe ser susceptible de valoración económica**.

El Código Civil y Comercial ha puesto particular énfasis en que la ley sea aplicada de conformidad con la Constitución y los tratados de derechos humanos. Así, el artículo 1º dispone que "los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho".

El artículo 2º añade que "la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento".

Cierto es que la pirámide normativa consagrada por la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, párrafos 2º y 3º, pone por encima de todo a la propia Constitución y a los tratados de derechos humanos, pero debe recordarse también que la referida norma, en su párrafo 1º, otorga a los tratados y concordatos jerarquía superior a las leyes, por lo que la aplicación del propio Código no podrá prescindir de tales tratados y concordatos, a pesar de que no hayan sido mencionados.

Entrando particularmente al tema de los contratos, entre los tratados de derechos humanos es necesario destacar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La primera proclama la necesidad de que los Estados parte procuren lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (art. 26); la segunda, que toda persona tiene derecho a obtener la satisfacción de los derechos económicos indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad (art. 22).

Estos tratados, entre otros, tienen particular relevancia para el derecho de los contratos. Es que si entre los objetivos se encuentra el desarrollo económico de las personas, una de las vías para lograrlo —quizás la más importante— sea el contrato, que resulta central para facilitar la circulación de bienes y servicios. Desde luego, no cualquier contrato será aceptable, pues si éste persigue fines ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o agrede la dignidad de la persona humana, carece

de todo valor.

2. La importancia del contrato; su significación ética y económica

El contrato es el principal instrumento de que se valen los hombres para urdir entre ellos el tejido infinito de sus relaciones jurídicas, es decir, **es la principal fuente de obligaciones**. Las personas viven contratando o cumpliendo contratos, desde operaciones de gran envergadura (por ej., compraventa de inmuebles, constitución de sociedades, construcción de obras de distinto tipo —edificios, represas, transporte de gas, etc.—), hasta contratos cotidianos que se realizan muchas veces sin advertir que está contratando: así ocurre cuando se trabaja en relación de dependencia (contrato de trabajo), cuando sube a un colectivo (contrato de transporte), cuando se compra alimentos (compraventa), cuando adquiere entradas para ir al cine o al fútbol (contrato de espectáculo público).

Es claro que el contrato adquiere su máxima importancia en un régimen de economía capitalista liberal. Desde el punto de vista ético, la importancia de los contratos se aprecia desde un doble ángulo: por una parte, hay una cuestión moral envuelta en el deber de hacer honra la palabra empeñada; por la otra, los contratos deben ser un instrumento de la realización del bien común. Ya veremos que este último aspecto moral del contrato es una de las razones que justifica el intervencionismo del Estado moderno.

3. Los derechos resultantes del contrato y el derecho de propiedad

El contrato es fuente de obligaciones y derechos. En efecto, al celebrarse cualquier contrato, nacen obligaciones en cabeza de las partes contratantes, quienes deberán cumplirlas de acuerdo con las pautas fijadas por ellas.

La obligación que cada una de las partes asuma importa un derecho en cabeza de la otra. Así, en una compraventa, la obligación que asume el comprador de pagar el precio estipulado importa el derecho del vendedor a cobrarlo, o la obligación que este último ha asumido de entregar la cosa vendida importa el derecho del comprador a recibirla.

Estos derechos que nacen del contrato forman parte del patrimonio de las personas involucradas. Por ello, el artículo 965 del Código Civil y Comercial dispone, con razón, que "los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante", lo que le otorga también la jerarquía constitucional que la propia Constitución da al derecho de propiedad (art. 17), consagrando legalmente lo que ya pacíficamente había establecido la jurisprudencia.

4. Metodología del Código Civil y Comercial en materia de contratos.

Antecedentes. Legislación comparada

El Libro Tercero del Código Civil y Comercial se dedica a los "Derechos personales". Este Libro se divide a su vez en cinco títulos, que se refieren respectivamente a las "Obligaciones en general", a los "Contratos en general", a los "Contratos de consumo", a los "Contratos en particular" y, finalmente, a "Otras fuentes de las obligaciones", en donde se refiere a la responsabilidad civil, la gestión de negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad y a los títulos valores.

Lo más importante del método de nuestro Código es la reunión de las disposiciones comunes a todos los contratos en un título particular. De todos modos, nos parece importante poner de relieve que esta parte general de los contratos no se agota en el título II del Libro Tercero. En efecto, no podrá prescindirse: a) de los contratos de consumo, regulados en el título III de este mismo libro; b) de las reglas referidas a la capacidad y a sus restricciones, fijadas en el Libro Primero, título I, capítulos 2 y 3; c) de lo previsto en materia de hechos y actos jurídicos (Libro Primero, título IV), sobre todo en lo que se trata de los elementos del acto jurídico y de los vicios tanto del consentimiento como del acto jurídico, y d) las disposiciones de derecho internacional privado fijadas en las secciones 10, 11 y 12, del capítulo 3, del título IV, del Libro Sexto.

§ 2.— Naturaleza jurídica

5. Naturaleza jurídica del contrato. Ubicación del contrato en la teoría general del acto jurídico.

El contrato es un acto jurídico. Recordemos la definición del artículo 259: "El acto jurídico es el acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas". Obvio es que dentro de ese concepto cabe el contrato. En otras palabras, acto jurídico es el género, contrato la especie. **El contrato es, entonces, un acto jurídico que tiene las siguientes características específicas: a) es bilateral, es decir, requiere el consentimiento de dos o más personas (sin perjuicio de lo que se dirá más adelante del unilateral); b) es un acto entre vivos; y c) tiene naturaleza patrimonial.**

6. El contrato como fuente de obligaciones. Su distinción respecto de otras áreas del derecho civil

Es necesario distinguir el contrato de otras áreas del derecho civil. Veamos:

a) De los derechos personalísimos

Los derechos personalísimos son aquellos que son innatos al hombre como tal, y de los cuales no puede ser privado. Se trata de derechos no patrimoniales, imprescriptibles, irrenunciables e intransmisibles (derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor, a la identidad, etc.). Con todo debe señalarse que existe algún punto de contacto con el contrato, desde que ciertos derechos personalísimos pueden ser dispuestos si el acto no es contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres (art. 55).

Es importante destacar que están prohibidos los actos de disposición sobre el propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico (art. 56). Y para acentuar el carácter restrictivo se dispone que "los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales" (art. 17).

b) De los actos jurídicos familiares

Los actos jurídicos familiares difieren del contrato tanto en su naturaleza como en su objeto. Más allá de que para la celebración de aquellos actos se requiera también el consentimiento de las partes, la regulación jurídica se rige imperativamente por las pautas legales. Así, por ejemplo, una vez contraído el matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges se rigen exclusivamente por las disposiciones de la ley.

Hasta en el régimen patrimonial del matrimonio se ve lo dicho anteriormente. Es cierto que el Código Civil y Comercial regula las denominadas convenciones matrimoniales y que ellas permiten a los cónyuges optar entre uno de los dos regímenes patrimoniales que se establecen (arts. 446 y 463 y ss.), pero hasta allí llega el derecho de los cónyuges. Una vez elegido uno de los dos regímenes, se lo aplica enteramente, sin posibilidad alguna de que los cónyuges lo modifiquen parcialmente.

c) De los derechos hereditarios

La diferencia entre sucesión y contrato es clara. Aun cuando haya existido un testamento, no hay contrato. El testamento es un acto jurídico unilateral, por el que se dispone de los bienes y que necesita, con posterioridad al fallecimiento del testador, la aceptación del heredero para que pueda hacerse efectiva la transmisión de tales bienes.

§ 3.— Evolución del contrato

7. La autonomía de la voluntad, la fuerza obligatoria y el efecto relativo en la realidad de nuestro tiempo

La autonomía de la voluntad, que etimológicamente importa el poder que tiene la voluntad de darse su propia ley, es la cualidad de la voluntad en cuya virtud el hombre tiene la facultad de autodeterminarse y de responsabilizarse por el cumplimiento de las obligaciones que asume.

La autonomía de la voluntad se vincula estrechamente con la fuerza obligatoria del contrato, en tanto lo que se procura es que el contrato libremente pactado (esto es, que haya sido celebrado con pleno discernimiento, intención y libertad, art. 260) obligue, sin más, a las partes. En otras palabras, el acuerdo contractual obliga a los contrayentes, pues si bien las personas son libres de obligarse o no, una vez que lo han hecho deben cumplir la obligación asumida o responder por su incumplimiento.

Finalmente, debe señalarse que los efectos generados por el contrato y, en general, por todo acto jurídico, recaen sobre las partes intervinientes y sobre sus sucesores (arts. 1021, 1023 y 1024). Son partes aquellos sujetos que, por sí o por representante, o a través de corredor o agente sin representación, se han obligado a cumplir determinadas prestaciones y han adquirido ciertos derechos.

Por otra parte, el Código Civil y Comercial consagra, en el artículo 1022, el principio que los actos jurídicos obligan solamente a las partes y, consecuentemente, no producen efectos respecto de terceros. Sin embargo, hemos de ver, cuando nos refiramos en extenso a los efectos de los contratos, que esta cuestión no es tan lineal.

8. Intervención del Estado en las convenciones de los particulares

La intervención del Estado en los contratos se da a través del dictado de leyes o decretos que impactan en ellos, o con la intervención de los jueces en los casos llevados a los tribunales.

Numerosos ejemplos existen para demostrar la intervención del Estado a través de normas jurídicas.

El juez, por su parte, desempeña hoy el papel de guardián de la equidad en los contratos. Su contralor se desenvuelve a través de los siguientes recursos, entre otros:

1) La teoría de la *lesión*, que le permite reducir las prestaciones excesivas y, a veces, anular los contratos en los que las contraprestaciones resultan groseramente desproporcionadas.

2) La *teoría de la imprevisión*, que le permite restablecer la equidad gravemente alterada por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que han transformado las bases económicas tenidas en mira al contratar.

9. Contratos paritarios. Contratos por adhesión. Contratos de consumo

La forma clásica del contrato es aquella que supone una deliberación y discusión de sus cláusulas, hechas por personas que gozan de plena libertad para consentir o disentir. Es lo que se denomina **contrato paritario**. El Código Civil y Comercial ha tenido particularmente en mira este tipo de contrato, estructurando sobre él la parte general de los contratos.

Más allá de la importancia del contrato paritario, sobre todo cuando se analiza singularmente su contenido económico, el mundo moderno ha traído nuevas formas de contratar más masificadas —para decirlo de alguna manera—, pero no menos importantes.

Empecemos por **el contrato por adhesión** (llamado también con cláusulas generales predispuestas), que es aquel en el cual una de las partes fija todas las condiciones, mientras que la otra, solo tiene la alternativa de rechazar o consentir. Es el caso del contrato de transporte de larga distancia celebrado con una empresa de servicio público que fija el precio del pasaje, el horario, las comodidades que se brindan al pasajero, etc.; éste solo puede adquirir o no el boleto. Lo mismo ocurre con los contratos de seguro en los que la aseguradora fija todas las condiciones y el tomador del seguro solo podrá decidir entre celebrar el contrato o no, pero no podrá discutir las condiciones fijadas.

La doctrina predominante le reconoce carácter contractual. La circunstancia de que no haya discusión de las condiciones y de que una de las partes solo pueda aceptar o rechazar no elimina el acuerdo de voluntades, porque la discusión no es de la esencia del contrato: lo esencial es que las partes coincidan en la oferta y la aceptación.

El Código Civil y Comercial regula este tipo de contrato al referirse a la formación del consentimiento, y no se limita a dictar normas referidas a la forma de prestar el consentimiento, sino que define al contrato por adhesión, establece los recaudos que deben cumplir las cláusulas predispuestas a la que se debe adherir, incluye normas referidas a la interpretación del contrato y establece las sanciones que corresponde aplicar a las cláusulas que sean abusivas.

Es importante destacar, también, al llamado *contrato de consumo*, que muchas veces, erróneamente, es vinculado con el contrato por adhesión, pero que no pueden ser asimilados, toda vez que existen contratos de consumo que no son celebrados por adhesión y hay de estos últimos que no son de consumo.

El contrato de consumo tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios, normalmente parte débil de la relación contractual. Ahora bien, a partir de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional (art. 42) comienza un proceso de ampliación de la noción de contrato de consumo, que ya existía en la ley 24.240 de defensa del consumidor, hasta abarcar a las llamadas relaciones de consumo.

El Código Civil y Comercial define al contrato de consumo como el "celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social" (art. 1093). También define a la relación de consumo como "el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor", lo que —como fácilmente se puede advertir— excede el marco contractual (art. 1092). No está de más señalar que existe una infinidad de contratos de consumo; basta citar a las compraventas de mercadería en un supermercado o de electrodomésticos, para tener una idea.

Sin entrar a discutir la conveniencia de que el contrato de consumo sea incorporado al Código (la misma duda puede plantearse respecto de la relación de consumo), lo cierto es que ello ha ocurrido (Libro Tercero, título III), dándosele autonomía conceptual desde que ha sido separado de los contratos en general, regulados en el mismo Libro, pero en el título II.

Finalmente, podemos señalar que, en algunas oportunidades, pueden existir los llamados *contratos forzados*. Ciertamente parece difícil hablar de consentimiento cuando la ley obliga a vincularse jurídicamente, aun en contra de la voluntad del

interesado. Pero hay casos en que ello ocurre, en aras de un interés social que se considera prevalente.

Uno de ellos es el contrato de seguro automotor obligatorio previsto en el artículo 68 de la ley 24.449, que obliga a todo automotor, acoplado o semiacoplado, a tener un seguro de acuerdo con las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra los daños que puedan causarse a terceras personas, sean o no transportadas. Es clara la pretensión de dar protección al tercero damnificado. Otro ejemplo es el de los contratos que deben suscribir las compañías concesionarias de un servicio público (electricidad, gas, teléfonos, transportes) con los usuarios; ellas no pueden negarse a contratar con quien, sujetándose a las reglamentaciones generales, lo pretende. Si existiera tal facultad, podría colocarse al usuario en una situación inadmisibles de carencia de un servicio esencial que se ha querido garantizar a todos.

CAPÍTULO II - CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

10. La clasificación de los contratos. Distintos criterios

Existen diferentes formas de clasificar los contratos, todos ellos persiguiendo un mismo objetivo: encontrar los rasgos comunes de ellos.

A. — CONTRATOS UNILATERALES Y BILATERALES

11. Concepto

Se llaman *contratos unilaterales* aquellos en los que una sola de las partes resulta obligada hacia la otra, sin que esta quede obligada, como ocurre en la donación, que solo significa obligaciones para el donante; *bilaterales* son los contratos que engendran obligaciones recíprocas entre las partes (art. 966), como ocurre en la compraventa, la permuta y la locación.

12. El contrato plurilateral

Finalmente, existe el llamado contrato plurilateral, cuyos rasgos distintivos son los siguientes: i) las obligaciones no son correlativas para las partes, sino que cada una adquiere derechos y obligaciones respecto de todas las demás; ii) el vicio del consentimiento de uno de los contratantes afecta su intervención pero no anula necesariamente el contrato; iii) las obligaciones de las partes pueden ser de objeto diferente que confluyen en un fin común (dar, aportar, hacer); iv) admite el ingreso de nuevas partes o el retiro de alguna de ellas; v) el incumplimiento de una de las partes no acarrea inexorablemente la resolución del contrato ni permite oponer la excepción de incumplimiento contractual.

Más allá de estas características propias del contrato plurilateral, el Código Civil y Comercial ha establecido que supletoriamente se le aplicarán las normas de los contratos bilaterales (art. 966).

B. — CONTRATOS ONEROSOS Y GRATUITOS

13. Concepto

Los contratos a título oneroso son aquellos en los cuales las partes asumen obligaciones recíprocas, de modo que se promete una prestación para recibir otra; tales son la compraventa (cosa por dinero), la permuta (cosa por cosa), la prestación de servicios (servicio por dinero) y la locación (goce de la cosa por dinero). Los contratos a título gratuito son aquellos en que una sola de las partes se ha obligado, en los que una sola asegura a la otra una ventaja, con independencia de toda prestación a su cargo: donación, comodato, depósito gratuito, etc. No deja de ser gratuito el contrato por la circunstancia de que eventualmente puedan surgir obligaciones a cargo de la parte que nada prometió; así, por ejemplo, el donatario está obligado a no incurrir en ingratitud. Pero esta obligación no tiene el carácter de contraprestación; no es, en el espíritu de las

partes, una compensación más o menos aproximada de lo que prometió el donante ni la razón por la cual éste se obligó.

14. Consecuencias

La distinción entre contratos a título gratuito y a título oneroso (art. 967) tiene una enorme repercusión jurídica. Las principales consecuencias son las siguientes:

- a) Los adquirentes por título oneroso están mejor protegidos por la ley que los adquirentes por título gratuito; por consiguiente: 1) La acción de reivindicación tiene mayores exigencias cuando se dirige contra quien adquirió la cosa por título oneroso. 2) La acción revocatoria no exige la prueba del *consilium fraudis* (que es el conocimiento que el tercero tiene del fraude o, al menos, la posibilidad de conocerlo) cuando el tercero adquirió la cosa por título gratuito; pero es indispensable si la hubo por título oneroso. 3) La garantía de evicción y contra los vicios redhibitorios solo procede, en principio, en los contratos onerosos. 4) La aplicación de la lesión no se concibe en los contratos gratuitos.

C.

— CONTRATOS CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS

15. Concepto

Son contratos **conmutativos** aquellos en los cuales las obligaciones mutuas están determinadas de una manera precisa; de alguna manera, estas contraprestaciones se suponen equivalentes desde el punto de vista económico. De ahí la calificación de conmutativos con la que se quiere expresar que las partes truecan o conmutan valores análogos. Ejemplos: la compraventa (salvo la hipótesis que en seguida veremos), la permuta, la prestación de servicios, el contrato de obra, etc.

Son **aleatorios** los contratos en los que las ventajas o las pérdidas, para al menos una de las partes, dependen de un acontecimiento incierto (art. 968). Tal es el caso del contrato de seguro.

16. Concepto; distintas clases de formas

Se llaman contratos *no formales* aquellos cuya validez no depende de la observancia de una forma establecida en la ley; basta el acuerdo de voluntades, cualquiera que sea su expresión: escrita, verbal y aun tácita. Son *formales* los contratos cuya validez depende de la observancia de la forma establecida por la ley.

Dentro de la categoría de contratos formales (art. 969), hay que hacer una distinción de la mayor importancia: los contratos cuya forma es requerida a los fines probatorios y aquellos en los cuales la formalidad tiene carácter constitutivo o solemne. Las formas solemnes (también llamadas *ad solemnitatem*), a su vez, se dividen en absolutas y relativas. El incumplimiento de la forma solemne absoluta trae aparejado la nulidad del acto celebrado; así, la donación de un inmueble debe hacerse por escritura pública inexorablemente (art. 1552). En cambio, el incumplimiento de la forma solemne relativa no acarreará la nulidad del acto sino que permitirá exigir el cumplimiento de la forma establecida por la ley; v.gr. la omisión de celebrar una compraventa inmobiliaria por escritura pública permite a cualquiera de las partes exigir la escrituración (arts. 285 y 1018). Finalmente, cuando se trata de una forma probatoria, ella solo tiene importancia a los efectos de la prueba del acto jurídico; por ejemplo, el contrato de locación, sus

prórrogas y modificaciones debe ser hecho por escrito (art. 1188), pero si se hubiera incumplido con esta forma, el contrato valdrá de todos modos si existe principio de ejecución o principio de prueba instrumental (art. 1020).

17. El carácter excepcional de la forma

Las formas tienen carácter excepcional en nuestro derecho. Salvo disposición expresa en contrario, los contratos no requieren forma alguna para su validez. En efecto, solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada (art. 1015).

E.

— CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS

18. Concepto

Son contratos *nominados* los que están previstos y regulados especialmente en la ley. Son los contratos más importantes y frecuentes y por ello han merecido una atención especial del legislador. Su regulación legal, salvo disposiciones excepcionales, solo tiene carácter supletorio; esto es, se aplica en caso de silencio del contrato, pero las partes tienen libertad para prescindir de la solución legal y regular de una manera distinta las relaciones. Por lo tanto, el propósito del legislador no es sustituir la voluntad de las partes por la de la ley; simplemente desea evitar conflictos para el caso de que las partes no hayan previsto cierto evento, lo que es muy frecuente. Para ello dicta normas inspiradas en lo que es costumbre convenir o que están fundadas en una larga experiencia o en una detenida consideración acerca de cómo puede ser hallado un equilibrio tolerable entre ambas partes y exigible en justicia a cada una de ellas.

Los contratos *innominados* no están legislados y resultan de la libre creación de las partes. No pierden su carácter de innominados por la circunstancia de que en la vida de los negocios se los llame de alguna manera, tal como ocurre, por ejemplo, con el contrato de garaje, el de espectáculo público, de excursión turística, etc.; lo que los configura jurídicamente como nominados es la circunstancia de que estén legislados. Muchas veces ocurre que nuevas necesidades van creando formas contractuales que tienden a tipificarse espontáneamente y a llevar una denominación común; cuando esa forma contractual adquiere importancia suficiente como para merecer la atención del legislador, éste la reglamenta: el contrato queda transformado en nominado.

19. Reglas aplicables a los contratos innominados

¿Qué reglas han de aplicarse a los contratos innominados? El artículo 970 dispone que deberán regirse en el siguiente orden: i) la voluntad de las partes; ii) las normas generales sobre contratos y obligaciones; iii) los usos y prácticas del lugar de celebración, y iv) las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que sean compatibles y se adecuen a su finalidad. Cabe señalar que cuando la norma se refiere a la voluntad de las partes se abarca tanto la voluntad expresa como la tácita de los contratantes. Por consiguiente, el silencio del contrato debe ser llenado por los jueces, acudiendo a las normas generales de los contratos y de las obligaciones, luego atendiendo a los usos y prácticas del lugar de celebración y, finalmente, si fuera necesario, a las normas de los contratos nominados que sean afines y que se adecuen a la finalidad económica o práctica perseguida por el contrato.

F. — CONTRATOS DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO, DIFERIDO, SUCESIVO O PERIÓDICO. EL CONTRATO DE LARGA DURACIÓN

20. Concepto

Con respecto al momento del cumplimiento, los contratos pueden clasificarse de la siguiente manera:

a) De *ejecución inmediata*: las partes cumplen con todos sus derechos y obligaciones en el momento mismo del contrato; tal es el caso de la compraventa manual, en el que la cosa y el precio se entregan en el mismo instante de contratar.

b) De *ejecución diferida*: las partes postergan el cumplimiento de sus obligaciones para un momento o varios momentos ulteriores; así ocurre en la venta hecha con condición suspensiva o cuyo pago se pacta en varias cuotas, las que comienzan a vencer al cabo de cierto tiempo pactado.

c) De *ejecución instantánea*: las partes cumplen sus obligaciones en un solo instante, momento este que puede ser el de la celebración del contrato o posterior a él.

d) De *ejecución continuada o periódica o de tracto sucesivo*: las relaciones entre las partes se desenvuelven a través de un período más o menos prolongado; tal es el contrato de prestación de servicios, la locación, la sociedad, etc. Dentro de esta especie deben ubicarse ciertos contratos en los cuales una de las partes cumple todas sus obligaciones desde el comienzo, quedando pendientes las de la otra parte. Así ocurre, por ejemplo, con la venta a plazos en la que la cosa se entrega al contratar, quedando el precio para ser satisfecho en cuotas periódicas hasta su extinción total; cosa parecida ocurre en el contrato oneroso de renta vitalicia.

Los contratos de tracto sucesivo y de cumplimiento diferido constituyen el dominio de acción de la teoría de la imprevisión: las cláusulas de una convención, que pueden haber sido equitativas en el momento de contratar, pueden resultar injustas debido a la transformación de las condiciones económicas entonces imperantes. Ya veremos más adelante cómo se resuelve este problema; por el momento solo hemos querido destacar el interés práctico de esta clasificación.

También es remarcable la diferencia que existe en torno de la cláusula resolutoria. En los contratos bilaterales se entiende implícita la facultad de resolverlos si una de las partes no cumpliera su obligación (art. 1087); sin embargo, si se trata de un contrato de tracto sucesivo, las prestaciones que se hayan cumplido quedarán firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos correspondientes si resultan equivalentes, son divisibles y han sido recibidas sin reserva respecto del efecto cancelatorio de la obligación (art. 1081, inc. b)).

21. Contratos de larga duración

La irrupción de los contratos de larga duración ha permitido advertir que, en muchos casos, el contrato no es un acto aislado sino que configura un verdadero proceso. En este punto, es necesario insistir en la importancia de estar dispuestos a una continua renegociación, en donde se contemplen no solo las posibles y muchas veces abruptas variaciones de precios (sea por devaluaciones monetarias, sea por cambios de cotización de productos o materias primas), sino también las innovaciones tecnológicas y los nuevos requerimientos de la comunidad (piénsese en el equilibrio que debe existir en la prestación de servicios, que debe ofrecer precios adecuados pero a la vez brindar prestaciones de avanzada).

El artículo 1011 establece que *en los contratos de larga duración el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Por tal motivo, las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración total. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos.*

La norma apunta a la importancia que tiene el factor tiempo en los contratos de larga duración, lo que pone de manifiesto las dificultades que se ciñen sobre los contratos cuando se los pretende inmodificables, quedando obligadas las partes inexcusablemente en los términos convenidos.

El mundo contemporáneo genera numerosos negocios jurídicos que vinculan a las partes por muchos años. Son, entre otros, los ejemplos de los contratos de concesión de servicios públicos o de obras viales, servicios de salud, tiempo compartido, *leasing*, fideicomiso y obras públicas (como construcción de represas).

Está claro que estos contratos no permiten situaciones cristalizadas. Se hace necesario admitir un proceso de permanente renegociación y de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones contractuales, para alcanzar la finalidad perseguida dentro de un marco de justicia contractual. Para ello, para alcanzar tales soluciones justas, será necesario atender a la calidad y eficiencia de las prestaciones prometidas, la competitividad de la economía, las inversiones y la rentabilidad empresarial, entre otros aspectos.

De allí la importancia de la norma legal citada (art. 1011), en cuanto impide extinguir sin más el contrato ante un incumplimiento, si es de larga duración, debiendo otorgar a la otra parte la oportunidad de renegociar de buena fe las pautas contractuales para no incurrir en un ejercicio abusivo de los derechos.

Sin embargo, debemos señalar que la operatividad de esta norma no resulta clara en algunos contratos de larga duración. En efecto, en los contratos por tiempo

indeterminado de suministro (art. 1183), agencia (art. 1492) y franquicia (art. 1522), el Código prevé un sistema de extinción contractual que no hace mención alguna a las pautas del artículo 1011. La prevalencia de las normas especiales sobre la norma general o la interpretación armónica de todas ellas será una cuestión a decidir teniendo en cuenta las particularidades del caso en concreto.

G.

— OTRAS CLASIFICACIONES

22. Contratos principales y accesorios

A veces hay entre los contratos una relación de subordinación. Uno de ellos es principal, es decir, puede existir por sí solo; el otro es accesorio y su existencia no se concibe sin el principal, de tal modo que, si éste fuera nulo o quedara rescindido o resuelto, también quedaría privado de efectos el accesorio. El ejemplo típico de contrato accesorio es la fianza.

Hay contratos que tienen una función de garantía; esto es, tienen como fin asegurar el cumplimiento de una obligación. Es el caso del contrato de fianza, por el cual el fiador asegura que el deudor cumplirá su obligación para con el acreedor, pero si ello no ocurriera, aquél deberá satisfacer el crédito.

Hay contratos que tienen una función de custodia o cuidado. Es el caso del contrato de depósito, por el cual quien recibe una cosa se obliga a cuidarla durante el tiempo fijado en el contrato y a entregarla sin daño a quien se la ha dado.

Hay contratos que tienen una función de cooperación, como ocurre con el contrato de sociedad, en el que los socios tienen diferentes obligaciones, pero todas ellas tienden a alcanzar el fin social previsto.

23. Concepto

Son contratos *consensuales* los que quedan concluidos por el mero consentimiento, sea o no formal. Son *reales* los que quedan concluidos solo con la entrega de la cosa sobre la cual versa el contrato. Así los definía el Código Civil de Vélez Sarsfield en los arts. 1140 y 1141.

De acuerdo con el concepto antes expresado, los contratos reales requieren como condición de su existencia la entrega de la cosa. El mero acuerdo de voluntades es ineficaz para obligar a las partes. Pero esta categoría parece carecer de sentido en el derecho moderno, en el que impera el principio de la autonomía de la voluntad; basta el acuerdo de voluntades expresado en la forma señalada por la ley para que el contrato tenga fuerza obligatoria, sin otro límite que la legitimidad de la causa y el objeto. Por eso, ha hecho bien el Código Civil y Comercial en suprimir esta clasificación.

CAPÍTULO III - ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS. EL CONSENTIMIENTO

24. Elementos de los contratos

La doctrina clásica distingue tres clases de elementos de los contratos: esenciales, naturales y accidentales:

a) Elementos *esenciales* son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir. Ellos son: el consentimiento, la causa y el objeto. En apretada síntesis, el consentimiento es la conformidad o el acuerdo que resulta de manifestaciones intercambiadas por las partes, el objeto es la prestación (bien o hecho) prometido por las partes y la causa es la finalidad perseguida por las partes y que ha sido determinante de su voluntad.

b) Elementos *naturales* son aquellas consecuencias que se siguen del negocio, aun ante el silencio de las partes; así, la gratuidad es un elemento natural de la donación; las garantías por evicción y por vicios redhibitorios, un elemento natural de los contratos a título oneroso.

c) Elementos *accidentales* son las consecuencias nacidas de la voluntad de las partes, no previstas por el legislador. Por ejemplo, la condición, el plazo, el cargo.

La capacidad no constituye un elemento del contrato, sino un presupuesto del consentimiento. En efecto, el consentimiento no puede ser dado válidamente sino por quien tiene capacidad para obligarse. En otras palabras, si la persona no es capaz para otorgar un acto jurídico en particular, el consentimiento que preste será nulo.

En cuanto a la forma, es cierto que, si las partes la incumplen, el acto jurídico celebrado será nulo, pero ello ocurrirá solamente en los pocos casos en los que la ley así lo establece (art. 969). En la mayoría de los contratos, el incumplimiento de la forma no acarrea la nulidad (art. citado). Por ello, no parece posible incluir a la forma dentro de los elementos esenciales del contrato en general porque, insistimos, el incumplimiento de ella no trae como regla la nulidad del acto, sino solo en los casos en que la ley así lo prevé expresamente.

§ 1.— Voluntad y declaración

25. Medios de manifestación del consentimiento

Dispone el artículo 971, al establecer cómo se produce la formación del consentimiento, que los "contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia del acuerdo".

El consentimiento es una declaración de voluntad, por lo que resultan aplicables las normas que regulan la manifestación de la voluntad. La voluntad puede manifestarse de manera expresa o tácita; es expresa cuando se exterioriza de manera oral, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material (art. 262); es tácita cuando resulta de actos que permitan conocer la voluntad con certidumbre y siempre que la ley no exija una manifestación expresa (art. 264). Incluso, en limitados casos, el silencio puede importar una manifestación de la voluntad. Ello ocurre cuando se opone el silencio a un acto o una interrogación y existe un deber de expedirse que resulta de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes (art. 263).

§ 2.— Formación del contrato

A.

— OFERTA

26. Concepto

Oferta es una proposición unilateral que una de las partes dirige a otra para celebrar un contrato. O, como lo define el Código Civil y Comercial, es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada (art. 972). No es un acto preparatorio del contrato, sino una de las declaraciones contractuales. Así, pues, solo hay oferta cuando el contrato puede quedar concluido con la sola aceptación de la otra parte, sin necesidad de una nueva manifestación del que hizo la primera proposición.

En consecuencia, la oferta debe ser distinguida:

a) De la *invitación a oír ofertas*, en la cual una persona se limita a hacer saber que tiene interés en celebrar cierto negocio y que escucha ofertas. Ejemplo típico es el de la subasta pública, en la que el martillero invita a formular propuestas, pero el contrato no queda concluido sino cuando hace la adjudicación a la más alta.

b) De la llamada *oferta al público* que ordinariamente no constituye sino una invitación a oír ofertas. Como es hecha a persona indeterminada no obliga al ofertante *excepto que de sus términos o de las circunstancias de emisión resulte la intención de contratar del oferente*, en cuyo caso se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos (art. 973).

Por ello, a menos que se trate de la excepción prevista, se requiere una declaración de voluntad del interesado y una ulterior aceptación de quien hizo la oferta general.

En línea con lo establecido en el Código Civil y Comercial, la ley 24.240, llamada de defensa del consumidor, establece desde que fue promulgada que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones (art. 7º).

Asimismo, configura una declaración obligatoria para el que la emite la oferta de objetos por medio de un aparato automático, en cuyo caso el contrato queda concluido con la conducta del comprador que introduce la moneda haciendo funcionar el mecanismo.

c) De la *opción contractual*, que es un contrato por el cual una de las partes hace una oferta con carácter irrevocable durante un cierto tiempo y la otra acepta la irrevocabilidad propuesta y se obliga a aceptar la oferta o rechazarla en ese mismo tiempo. En esta hipótesis hay algo más que una promesa unilateral, desde que ha mediado ya un acuerdo de voluntades.

d) Finalmente, debe distinguirse de las *tratativas previas* al contrato y aun de los *contratos preliminares*. En estos no hay todavía una voluntad definitiva de vincularse jurídicamente; se está solo en tanteos y negociaciones más o menos adelantadas, pero que no han llegado a la concreción de una propuesta firme y definitiva.

27. Requisitos de la oferta

Según el artículo 972, para que haya oferta válida es necesario:

a) Que se dirija a *persona o personas determinadas o determinables*.

b) Que tenga por objeto un contrato determinado, *con todos los antecedentes constitutivos de los contratos*. O, con palabras del Código Civil y Comercial, que tenga las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Es decir, la propuesta debe contener todos los elementos necesarios como para que una aceptación lisa y llana permita tener por concluido el contrato. Así, por ejemplo, si se trata de una compraventa, será necesario que la oferta contenga la determinación de la cosa y el precio; faltando cualquiera de estos elementos, no habrá oferta válida, pues ellos son esenciales en dicho contrato.

c) Que exista *intención de obligarse*. Todo acto jurídico (y la oferta lo es) requiere que sea ejecutado con intención para ser válido (art. 260). Por ello, si no hay verdadera intención de obligarse, no hay oferta. Es el caso de la oferta hecha con espíritu de broma o sin entender obligarse, como, por ejemplo, las palabras pronunciadas en una representación teatral.

28. Duración de la oferta; revocación; caducidad

¿En qué medida queda obligado el oferente por su sola oferta?

La regla primaria es que la oferta obliga al proponente. Con otras palabras, quien emite una oferta se está obligando a cumplir con las prestaciones prometidas si el destinatario de ella la acepta.

Desde luego, esta fuerza obligatoria de la oferta puede tener limitaciones, las que, a tenor de lo que dispone el artículo 974, párrafo 1º, nacen de los términos de la oferta (como ocurriría cuando se establece un límite de vigencia de la oferta), de la naturaleza del negocio (es el caso de la oferta contractual que tiene por objeto una cosa que está sujeta a un riesgo) o de las circunstancias del caso (cuando se ofrece, por ejemplo, un hacer que importa una obligación *intuitu personae*).

El Código Civil y Comercial (art. 974, párrs. ss.) distingue entre la oferta con y sin plazo de vigencia. A su vez, en este último caso, diferencia entre ofertas hechas a persona presente o formulada por un medio de comunicación instantáneo y a personas que no están presentes.

Si en la oferta se establece un plazo de vigencia, la oferta valdrá solo por ese plazo, el que comenzará a correr desde la fecha de su recepción excepto que contenga una previsión diferente.

Si en la oferta no se establece un plazo de vigencia y ella es hecha a persona presente o se la formula por un medio de comunicación instantáneo, solo puede ser aceptada de inmediato. Si ello no ocurre, la oferta caduca.

En cambio, si la oferta se hace a una persona que no está presente, sin que se haya fijado un plazo para su aceptación, el oferente queda obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta, expedida por el aceptante por los medios usuales de comunicación.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que si la oferta es dirigida a una persona determinada, ella puede ser retractada. Para ello, es necesario que la comunicación del retiro de la oferta sea recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la propia oferta (art. 975).

Finalmente, existen supuestos de caducidad de la oferta; esto es, que pierde su fuerza obligatoria. Ello acaece cuando el proponente o el destinatario de la oferta fallecen o se incapacitan antes de la recepción de su aceptación. Con todo, se le reconoce un derecho a quien aceptó la oferta ignorando la muerte o incapacidad del oferente: si a consecuencia de su aceptación ha hecho gastos o sufrido pérdidas, tiene derecho a reclamar su reparación (art. 976).

29. Concepto

La aceptación de la oferta consume el acuerdo de voluntades. Para que se produzca su efecto propio (la conclusión del contrato) es preciso: a) que sea *lisa y llana*, es decir, que no esté condicionada ni contenga modificaciones de la oferta; b) que sea *oportuna*; no lo será si ha vencido ya el plazo de la oferta, que puede ser expreso o resultar de los usos y costumbres o de un tiempo que pueda considerarse razonable para recibir la respuesta.

La aceptación debe referirse a todos los puntos de la propuesta; basta el desacuerdo con uno solo de ellos, aunque sea secundario, para que el contrato quede frustrado.

Hay aceptación cuando existe una declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la oferta. Incluso, el silencio, si bien como regla no puede ser tenido como una aceptación, sí lo será si existe el deber de expedirse, el que puede resultar de la voluntad de las partes —porque así lo han pactado—, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes (art. 979).

30. Modificación de la oferta

Si la oferta se aceptara con modificaciones, el contrato no queda concluido y la aceptación se reputa como una nueva oferta (llamada *contrapropuesta* o *contraoferta*) que debe considerar el oferente originario. Sin la aceptación de éste, no hay contrato.

El artículo 978 añade que las modificaciones hechas por el aceptante pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica a aquél de inmediato. En verdad, poco importa que la aceptación del oferente sea de inmediato. Aunque ello no ocurra, es claro que, si el oferente acepta los cambios introducidos por el aceptante, habrá contrato. Es que, en este caso, la modificación hecha por el aceptante importa colocarlo a él como oferente y el oferente inicial, al aceptar la propuesta recibida, se ha convertido en aceptante del contrato.

31. Perfeccionamiento del contrato

La aceptación perfecciona el contrato. Pero debe diferenciarse según se trate de un contrato entre presente o entre ausentes.

En el primer caso, la aceptación perfecciona el contrato cuando ella es manifestada; en el segundo caso, la aceptación perfecciona el contrato cuando ella es recibida por el proponente, siempre que ello ocurra dentro del plazo de vigencia de la oferta (art. 980).

32. Oferta hecha a persona presente o por un medio de comunicación instantáneo

La oferta hecha a persona presente o por un medio de comunicación instantáneo, como puede ser el teléfono o un sistema informático *online*, no se juzgará aceptada si no lo fuese inmediatamente (art. 974). Es un supuesto en que el receptor de la oferta no goza de plazo, a menos que se le concediera expresamente. Se trata de una disposición razonable, fundada en lo que es corriente en la vida de los negocios.

33. Contratos por teléfono

¿Los contratos concluidos por teléfono deben considerarse celebrados entre presentes o ausentes? Esta cuestión, que otrora dio origen a controversias, puede hoy considerarse superada. Se acepta generalmente la necesidad de hacer el siguiente distingo:

a) En lo relativo al *momento* de la conclusión del contrato, se reputa celebrado entre presentes. Por consiguiente, la aceptación debe seguir inmediatamente a la oferta (Código Civil alemán, art. 147; de las Obligaciones suizo, art. 4º; brasileño, art. 428; mexicano, art. 1805; paraguayo, art. 675).

b) En lo relativo al *lugar* de la conclusión se lo reputa entre ausentes. Por consiguiente, la forma del contrato se regirá por las leyes y usos vigentes en el lugar de

la aceptación (arg. art. 2649), que es el lugar en que quedó perfeccionado el contrato.

34. Contratos celebrados a través de sistemas informáticos

En materia comercial, es frecuente que tanto la oferta como la aceptación de un contrato se hagan a través de sistemas informáticos. Tales contratos deben reputarse hechos entre ausentes, tanto en lo relativo al momento como al lugar de la celebración.

Alguna diferencia existe, en cambio, si se trata de contratos celebrados a través de medios digitales entre personas que están comunicadas a través de sistemas informáticos interconectados. La manifestación se realiza mediante un simple clic del *mouse*. Este contrato podrá ser juzgado como celebrado entre ausentes o presentes según las circunstancias del caso. Así, si el negocio se concreta por operaciones *online* (comunicación interactiva o simultánea), se entenderá que el contrato ha sido celebrado entre presentes, pues la aceptación es inmediatamente conocida (por ej., la reserva de un pasaje aéreo); por el contrario, se juzgará como celebrado entre ausentes si la aceptación no es emitida *online* o requiere de una confirmación posterior por el oferente enviada por otro medio (sea fax, teléfono o correo electrónico). Es a esa comunicación *online* a la que se refiere el artículo 974 cuando, hablando de la oferta formulada por un medio de comunicación instantáneo, sin fijación de plazo, dispone que ella solo puede ser aceptada inmediatamente.

35. Retracción de la aceptación

La aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella (art. 981). Como puede advertirse, se sigue un criterio idéntico al de la retractación de la oferta.

C.

— CONTRATOS ENTRE AUSENTES

36. Momento en que se reputa concluido el contrato; distintos sistemas

¿Cuándo debe reputarse concluido el acuerdo de voluntades en los contratos entre ausentes? Sistema del Código Civil y Comercial

El Código Civil y Comercial, apartándose del precedente Código Civil, ha consagrado la teoría de la recepción (art. 971).

Debe señalarse que se considera que la manifestación de voluntad de una de las partes (sea la oferta, sea la aceptación) es *recibida* por la otra parte, cuando esta última *la conoce o debió conocerla*, trátase de comunicación verbal, de recepción en su domicilio de un instrumento pertinente o de otro modo útil (art. 983).

Si bien se habla del conocimiento de la manifestación de la voluntad, lo que podría dar a entender que estamos ante una aplicación de la teoría de la información, la ley presume tal conocimiento cuando el receptor de tal manifestación debió conocerla. Y ello solo puede ocurrir a partir del momento en que la recibió. Basta, entonces, la recepción para que se tenga por conocida la manifestación de voluntad.

CAPÍTULO VI - INEFICACIA DEL CONTRATO

37. Ineficacia del contrato. Nulidad.

Cuando nos referimos a la ineficacia del contrato, apuntamos a ciertos vicios que pueden afectarlo. Ya hemos visto cómo la incapacidad o la restringida capacidad de uno de los contratantes provoca la nulidad del contrato celebrado, y, por lo tanto, lo torna ineficaz.

Pero, además, la ineficacia puede tener otras causas. En efecto, el contrato puede estar afectado por los llamados vicios del consentimiento, esto es, que el contratante ha dado su conformidad bajo los efectos de un vicio (error, dolo o violencia) que afectaba su voluntad. Otras veces, el contratante tiene plena conciencia del contrato que está celebrando, pero ocurre que el propio acto jurídico puede estar viciado, sea por la situación de inferioridad de uno de los contratantes, sea porque se trata de un contrato simulado o hecho en fraude de terceros.

En todos estos casos, será nulo.

38. La nulidad del contrato y sus efectos entre las partes

El principio general en esta materia está sentado en el artículo 390: la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo. La solución es perfectamente lógica, puesto que anular implica tenerlo por no ocurrido. Ya veremos, sin embargo, cómo la cuestión, que desde el punto de vista lógico parece simple, presenta ciertos problemas.

Ante todo, es necesario distinguir dos hipótesis distintas: a) que el contrato no haya sido ejecutado; en tal caso, declarada la nulidad, no es posible exigir el cumplimiento de las obligaciones que de él derivan; más aún, si la nulidad aún no ha sido declarada, puede ser opuesta por vía de excepción por el interesado (art. 383); b) que el contrato haya sido parcial o totalmente ejecutado; esta es la hipótesis que da lugar a mayores dificultades, como veremos seguidamente.

La nulidad obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido en virtud del acto declarado nulo (art. 390). La norma añade que estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe, según sea el caso, de acuerdo con lo dispuesto respecto de los efectos de las relaciones de poder, en los artículos 1932 y siguientes.